

<입문-제8장 행정쟁송.제2절 행정소송 개관>

**I. 행정소송의 의의**

**1. 개념**

- 행정소송이란 행정청의 위법한 처분이나 공권력의 행사·불행사 등으로 인하여 권리나 이익을 침해받은 국민이 사법부인 법원에 제소하여 그 위법성을 다투고 구제를 받는 절차를 말한다. 행정소송에 관한 일반법은 행정소송법이다. 행정소송은 행정부 내부의 통제 절차인 행정심판과 구별되는 사법부의 통제 절차이다.

**2. 목적**

- 행정소송은 행정 권력에 대한 사법 통제를 통해 국민의 권익을 최종적으로 보장하고, 행정의 적법성을 확보하여 법치 행정을 실현하는 데 궁극적인 목적이 있다.

**II. 행정소송의 종류**

**1. 내용에 따른 분류**

**(1) 주관적 소송**

- 주관적 소송이란 국민의 권리 또는 이익의 보호를 목적으로 제기하는 소송을 말한다. 행정소송법은 주관적 소송으로서 항고소송과 당사자소송을 규정하고 있으며, 이는 국민의 권리 구제를 주된 목적으로 하는 행정소송의 핵심적인 형태이다.

**(2) 객관적 소송**

- 객관적 소송이란 개인의 권리 또는 이익의 보호와 관계없이 행정법 질서의 유지와 적정한 집행을 보장하기 위하여 제기하는 소송을 말한다. 행정소송법은 객관적 소송으로서 민중소송과 기관소송을 규정하고 있다. 민중소송은 국가 또는 공공단체의 기관이 아닌 일반 국민이 제기하는 소송이며, 기관소송은 국가 또는 공공단체의 기관 상호 간에 권한의 존부 또는 행사에 관하여 다툼이 있을 때 제기하는 소송이다.

**2. 성질에 따른 분류**

**(1) 형성의 소**

- 형성의 소란 법원의 판결에 의하여 새로운 법률 관계를 형성시키거나 기존의 법률 관계를 변경·소멸시키는 것을 목적으로 하는 소송이다. 행정소송 중 취소소송은 법원의 판결로 행정처분을 취소하여 그 효력을 소멸시킨다는 점에서 대표적인 형성의 소에 해당한다.

**(2) 이행의 소**

- 이행의 소란 법원의 판결로 상대방에게 일정한 행위를 할 것을 명하는 것을 목적으로 하는 소송이다. 행정소송에서 의무 이행을 직접 구하는 소송은 행정소송법상 명시적으로 인정되지 않으며, 당사자소송 중 공법상 금전 급부 청구 소송 등이 이에 해당할 수 있다.

**(3) 확인의 소**

- 확인의 소란 법원의 판결에 의하여 특정한 권리 또는 법률 관계의 존부를 확인하는 것을 목적으로 하는 소송이다. 행정소송 중 무효등확인소송은 처분의 효력 유무나 존재 여부를 확인한다는 점에서 대표적인 확인의 소에 해당한다. 부작위위법확인소송은 행정청의 부작위가 위법하다는 사실 자체를 확인하는 소송이다.

**III. 행정소송의 절차(취소소송)**

- 취소소송은 행정소송의 중심적인 유형으로서, 그 절차는 다음과 같다.

**1. 피고 적격**

- 취소소송의 피고는 원칙적으로 그 처분을 행한 행정청이 된다.

**2. 제소 기간**

- 취소소송은 처분 등이 있음을 안 날부터 90일 이내 또는 처분 등이 있었던 날부터 1년 이내에 제기되어야 한다. 이는 국민의 권리 구제와 행정의 안정성 확보를 조화시키기 위한 것이다.

**3. 관할 법원**

- 피고의 소재지를 관할하는 행정법원이 관할 법원이 된다.

**4. 심리**

- 법원은 당사자가 제출한 증거와 자료를 바탕으로 처분의 위법성을 심리한다. 법원은 직권으로 증거 조사를 할 수 있는 직권 탐지주의가 일부 가미되어 있다.

**5. 판결**

- 심리 결과에 따라 각하, 기각, 인용 등의 판결을 내린다.

**IV. 처분 등 개념 요소**

- 취소소송의 대상이 되는 처분 등의 개념은 행정소송법 제2조 제1호에 규정되어 있으며, 이는 항고소송의 대상을 한정하는 핵심적인 요소이다.

**1. 행정청의 행위**

- 처분은 행정청이 행하는 행위여야 한다. 여기서 행정청이란 국가 또는 공공단체의 의사를 외부에 표시할 권한을 가진 기관을 말한다.

**2. 구체적 사실에 관한 행위**

- 처분은 구체적 사실에 관한 행위여야 하며, 일반적이고 추상적인 규정인 법규 명령은 원칙적으로 처분이 될 수 없다. 다만, 일반적·추상적 규정이라도 그 규정만으로 직접적이고 구체적인 권리 의무에 영향을 미치는 경우(집행 행위의 매개 없이)에는 예외적으로 처분성이 인정될 수 있다(법규명령의 처분성).

**3. 법 집행 행위(규율 행위)**

- 처분은 법률을 집행하는 행위, 즉 법규에 의한 규율 행위여야 한다. 법 집행과 관계없는 사실 행위는 원칙적으로 처분이 될 수 없다. 다만, 권력적인 사실 행위는 예외적으로 처분성이 인정될 수 있다.

**4. 공권력의 행사**

- 처분은 행정청이 우월한 지위에서 행하는 공권력의 행사여야 한다. 사법상의 계약이나 공법상의 계약은 원칙적으로 처분이 아니다.

**5. 거부 행위-소극적 처분**

- 행정청의 거부 행위는 국민에게 법규상 또는 조리상 신청권이 인정되고, 그 거부 행위가 신청인의 권리 의무에 직접적인 영향을 미치는 경우에는 소극적 처분으로 인정되어 취소소송의 대상이 된다.

## 6. 그 밖에 이에 준하는 행정작용

- 행정소송법은 처분 외에 그 밖에 이에 준하는 행정작용도 포함한다고 규정하고 있다. 이는 행정청의 처분은 아니지만, 국민의 권리 의무에 직접적인 영향을 미치는 공권력 행사를 포괄적으로 소송 대상으로 인정하려는 취지이다.

## V. 취소소송의 심리

### 1. 개념

- 취소소송의 심리란 법원이 처분 등의 위법성 유무를 판단하기 위하여 사실 관계를 확정하고 법률을 해석·적용하는 절차를 말한다. 행정소송은 민사소송과 달리 공익성을 고려하여 변론주의가 적용되면서도 직권탐지주의가 일부 가미된 형태를 취한다.

### 2. 심리의 내용

#### (1) 위법성 심사

- 법원은 행정청의 처분이 법률에 위반되는지 여부만을 심사한다. 행정심판과 달리 처분의 부당성은 심사 대상이 되지 않는다. 처분의 위법성은 처분 당시의 법령과 사실 상태를 기준으로 판단하는 것이 원칙이다(처분 시 기준설).

#### (2) 재량 행위의 심사

- 행정청에게 법률상 재량권이 부여된 경우에는, 법원은 행정청의 재량 행위가 재량권의 한계를 넘거나 남용되었는지 여부만을 심사한다. 법원이 재량권 행사의 내용까지 직접 심사하여 대체하는 것은 권력 분립의 원칙에 위반되므로 허용되지 않는다.

#### (3) 직권 심리

- 법원은 필요하다고 인정할 때에는 당사자가 주장하지 않은 사항에 대해서도 직권으로 심리할 수 있는 직권 심리권을 가진다. 이는 공익과 관련된 행정 사건의 특성을 반영한 것이다.

## VI. 취소소송의 판결

### 1. 판결의 의의

- 판결이란 법원이 소송 절차를 통해 사건을 심리한 후, 그 소송에 대한 최종적인 판단을 외부에 표시하는 행위를 말한다. 취소소송의 판결은 국민의 권리 구제와 행정의 적법성 확보에 결정적인 영향을 미친다.

### 2. 판결의 종류

#### (1) 소송판결(각하판결)

- 소송요건의 적부에 대한 판결로서 요건심리의 결과, 당해 소송을 부적합한 것으로 각하하는 판결이다.

#### (2) 본안판결

- 본안심리(= 처분의 위법성 여부 심리)의 결과, 청구의 전부 또는 일부를 인용하거나 기각하는 판결이다(인용판결·기각판결).

#### (3) 기타

- 전부판결·일부판결, 중간판결·종국판결이 있다.

### 3. 종국 판결

#### (1) 각하판결

- 각하판결은 소송 요건을 갖추지 못하여 본안 심리를 할 수 없을 때, 본안에 대한 판단 없이 소송을 배척하는 판결이다. (제소 기간 도과, 원고 적격 흠결 등)

#### (2) 기각판결

- 기각판결은 소송 요건은 갖추었으나, 본안 심리 결과 처분의 위법성이 인정되지 않을 때 원고의 청구를 배척하는 판결이다.

#### (3) 인용판결

- 인용판결은 소송 요건을 갖추었고, 본안 심리 결과 처분의 위법성이 인정될 때 원고의 청구를 받아들여 처분을 취소하는 판결이다. 법원은 취소 판결 외에 처분의 변경 판결도 내릴 수 있다.

### 4. 판결의 방식과 절차

- 판결은 원칙적으로 공개 변론을 거쳐 선고되며, 판결서에는 주문과 이유를 명시해야 한다. 판결이 선고되면 당사자에게 송달된다.

### 5. 판결의 효력

#### (1) 기속력

- 기속력이란 판결의 취지에 따라 당사자인 행정청과 관계 행정청이 동일한 위법을 반복하지 않도록 구속하는 효력을 말한다. 행정청은 판결의 취지에 따라 재처분할 의무를 지게 된다.

#### (2) 기판력

- 기판력이란 확정된 판결의 내용이 후소에 구속력을 가지는 것을 말한다. 취소소송의 판결 역시 기판력을 가지며, 동일한 소송물에 대해서는 다시 소송을 제기할 수 없다.

#### (3) 형성력

- 형성력이란 취소 판결이 확정되면 그 판결에 의해 행정 처분의 효력이 소멸되는 것을 말한다. 취소 판결은 그 처분을 받은 당사자 외의 제3자에 대해서도 효력이 미치는 대세적 효력을 가진다.

## VI. 결론

- 행정소송은 행정청의 위법한 공권력 행사에 대한 사법 통제로서 국민의 권익을 구제하는 최종적인 절차이다. 행정소송은 항고소송, 당사자소송, 민중소송, 기관소송으로 분류되며, 항고소송중 취소소송은 행정소송의 가장 중심이며, 법원의 위법성 심사를 거쳐 형성력, 기속력을 가지는 판결을 통해 행정의 적법성을 확립한다.